

1501856-31.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... o réu confessou a prática do tráfico de entorpecentes. Esclareceu que trabalhou anteriormente para o tráfico e foi preso por isso. Possui dívida com os traficantes e, por tal razão, tornou a trabalhar com o tráfico, visando encerrar a dívida e ainda conseguir drogas para seu consumo pessoal. Receberia R\$ 150,00 por dia de "trabalho".

Interrogado em Juízo, o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501856-31.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501856-31.2021.8.26.0537 2021/001599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELVEN COSTA ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

KELVEN COSTA ROCHA, qualificado à fl. 15, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 08h20, na Rua Vega, altura do nº 100, Inamar, nesta cidade e Comarca de Diadema, trazia consigo para fins de mercancia e entrega a terceiros, 10 porções de cocaína, com peso de 08g., e 87 porções de maconha, pesando 50g., substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Dispensada a realização da audiência de custódia em razão da situação de pandemia da Covid-19, o flagrante foi apreciado pelo juízo da custódia, que o converteu em preventiva (fls. 46/48).

O réu foi notificado à fl. 76 e apresentou defesa preliminar às fls. 87/88.

Denúncia recebida em 03/11/2021 (fls. 89/90) e citação realizada à fl. 134.

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foi ouvida uma testemunha policial, interrogou-se o réu e prosseguiu-se com os debates orais entre a acusação e a defesa. Homologou-se, no ato, a desistência de oitiva da testemunha Amaro.

Em alegações finais, a D. Promotora de Justiça requereu procedência do pedido, condenando-se a ré nos termos da denúncia, sustentando que a prática do tráfico ficou bem demonstrada nos autos em razão da prova colhida em juízo e, ainda que

assim não fosse, o réu confessou que estaria cooperando com a prática do tráfico, incidindo o artigo 29 do Código Penal ao caso. Nada ponderou quanto à dosimetria da pena.

A D. Defesa, por sua vez, afirmou que o acusado não teria praticado qualquer dos verbos constantes do artigo 33 da Lei de Drogas. Sustentou que o réu somente foi preso porque está respondendo por outro processo e porque teria confessado informalmente em sede policial. Assim, requereu a absolvição com base no artigo 386, inciso V, do CPP e, subsidiariamente, o reconhecimento da incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecendo-se a incidência da figura do privilégio e a aplicação da multa no mínimo legal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante nos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitativa restou sobejamente comprovada pelo teor do boletim de ocorrência (fls. 09/11), do laudo de constatação (fls. 12/14), do auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), do laudo pericial de objeto (fls. 118/119), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 120/122) e da prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Interrogado em sede policial, o réu confessou a prática do tráfico de entorpecentes. Esclareceu que trabalhou anteriormente para o tráfico e foi preso por isso. Possui dívida com os traficantes e, por tal razão, tornou a trabalhar com o tráfico, visando encerrar a dívida e ainda conseguir drogas para seu consumo pessoal. Receberia R\$ 150,00 por dia de "trabalho".

Interrogado em Juízo, o réu afirmou que não é verdade que estava em posse da sacola, tendo sido abordado pelo outro policial, que não estava presente no ato. O outro policial o abordou, pegou seus documentos e depois encontrou na viela o pacote com as drogas, tendo sido imputada como de sua propriedade. O menino que estava com as drogas foi liberado pelos policiais. Estava trabalhando no local dos fatos como olheiro, era o último dia que ali trabalhava para saldar uma dívida que tinha. Os policiais viram que já tinha passagem anterior, então liberaram o outro moleque e o prenderam. As drogas estavam guardadas sobre um telhado, existente no local. Estava descendo a viela, quando o policial veio com o outro moleque e também o abordou, tendo liberado o menino e o prendido. Não conhecia o policial ouvido em juízo antes dos fatos.

Os demais elementos de prova corroboram a confissão extrajudicial e são suficientes a demonstrar a prática do crime de tráfico pelo réu.

Com efeito, em depoimento bastante seguro, a testemunha Flávio Augusto Moreira dos Santos, policial militar, afirmou que o local é conhecido por ocorrer a venda e uso de entorpecentes. A viatura estava em patrulhamento preventivo quando notou que, na VIELA VEGA, havia um indivíduo com uma sacola em mãos e ele, ao notar a viatura, apresentou bastante nervosismo. O indivíduo empreendeu uma fuga rápida, mas foi abordado e detido e, na sacola que ele dispensou, pouquíssimos metros atrás, havia entorpecentes. Nesse momento foi-lhe dada voz de prisão. Não conhecia o réu antes dos fatos. A VIELA VEGA é bem estreita e já é de conhecimento. A VIELA também é conhecida como PASSAGEM JOSÉ VICENTE, pois fica na Rua José Vicente. No local da abordagem há uma escola e uma UBS próximas, a UBS faz divisa com a UBS e os fundos fazem divisa com a UBS, é comum que as pessoas escondam resquícios de drogas no muro da UBS. A escola fica a cerca de cinquenta metros do local. O réu estava em posse da sacola, acreditando que por isso ele demonstrou excesso de nervosismo. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que a escola fica de muro colado com a UBS, sendo de fácil acesso para quem estava na viela.

Cabe ressaltar, nesse passo, que a palavra do policial militar, que atuou de maneira tão direta, não pode ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhe depositou a tarefa de vigilância e segurança, desconsiderasse sua palavra justamente quando presta conta

de sua diligência.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando nas comunidades verdadeira "lei do silêncio", por temer sofrer represálias.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que o policial conhecesse previamente o réu ou que tivesse motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheci e que sabe ser inocente. Ressalte-se que o próprio acusado nada falou a esse respeito.

Assim, a credibilidade do testemunho do policial não pode ser afastada.

Dessa forma, a significativa quantidade de droga apreendida em poder do réu (10 porções de cocaína, com peso de 08g., e 87 porções de maconha, pesando 50g.), e as circunstâncias em que se deu sua prisão (o réu estava em local conhecido como ponto de tráfico e correu quando notou a aproximação dos policiais, levando consigo uma sacola. Contudo, os policiais foram em seu encalço e conseguiram detê-lo e abordá-lo, tendo encontrado na sacola que ele trazia as porções de entorpecentes acima indicados, bem como a quantia de R\$ 73,50, em dinheiro), somada às confissões extrajudicial, evidenciam que, efetivamente, a droga encontrada em poder do réu lhe pertencia e se destinava à entrega a consumo de terceiros, bem caracterizando a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mostrando-se impossível, por consequência, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a prática do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Some-se a isso o fato do réu ter afirmado, em seu interrogatório judicial, que estava participando do tráfico na condição de olheiro, como forma de saldar uma dívida que já tinha.

Cabe ressaltar que a condição de viciado da réu não ficou comprovada nos autos e que a mera alegação de que é usuário não é suficiente para excluir a prática do crime, pois é sabido que usuários de drogas acabam se envolvendo com o tráfico com a finalidade de sustentar o próprio vício, sendo esta, inclusive, a hipótese dos autos.

Frise-se, ainda, que a quantidade de droga encontrada em poder do réu é suficiente para afastar a possibilidade de que se tratasse de substância para consumo pessoal, especialmente porque acompanhada de quantia em dinheiro, a evidenciar a disseminação anterior de outras porções a usuários.

Quanto a esse aspecto, cumpre salientar que, por ocasião do julgamento proferido no 'habeas corpus' 144.716/SP, junto ao Supremo Tribunal Federal, o Ministro relator, Dr. Celso de Mello, invocando o direito comparado, notadamente a Lei nº 30/2000, em vigência na República de Portugal, e a Portaria nº 94/96, editada pelo Ministério da Justiça e da Saúde daquele país, apontou que, pelo Supremo Tribunal de Justiça, órgão de cúpula da Justiça portuguesa, em aplicação da referida legislação tem sido adotada como parâmetro para diferenciação entre porte de drogas para consumo pessoal e a prática de tráfico ilícito de entorpecentes "a quantidade para consumo médio individual para um período de dez dias, a qual seria equivalente "a 2 gramas (se se tratar de cocaína) ou a 25 gramas (se se cuidar de maconha)". Logo, aplicando-se tal parâmetro ao caso, é possível concluir que a quantidade de droga encontrada em poder do réu é suficiente para afastar a possibilidade de que se tratasse de substâncias para consumo pessoal.

Por fim, quanto a causa de aumento de pena, não se pode desconsiderar que a prova oral evidenciou que o tráfico de entorpecentes ocorria ao lado do equipamento de saúde UBS Jardim Infamar, sendo o muro e o telhado da UBS utilizados para esconderijo dos entorpecentes. Desta forma, à evidência, a comercialização de entorpecentes atingia negativamente os usuários do estabelecimento de saúde, ainda que não de forma direta (o que é irrelevante dada a natureza objetiva da referida causa) ensejando a aplicação do aumento da pena.

Já com relação à escola municipal, estava fechada ao tempo dos fatos em razão da situação da pandemia, não sendo, portanto, relevante a sua proximidade em relação ao local dos fatos.

Assim, não restou configurada nenhuma causa de exclusão de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, havendo provas suficientes para que seja condenado o réu nas sanções

do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo, deste modo, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é tecnicamente primário e sem maus antecedentes, já que o outro feito a que está respondendo ainda está em tramitação. Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo a pena-base no piso legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda fase, mesmo presentes as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (em sede extrajudicial) e da menoridade relativa (réu nascido em 13/05/2001 - fl. 15), impossível a redução da pena, que já se encontra no piso legal, pois, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser conduzida abaixo deste patamar, neste momento do cálculo. Assim, permanece a pena nos moldes em que se encontrava.

Na derradeira etapa, verifica-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (UBS Inamar), como acima fundamentado, ensejando a aplicação do aumento da pena na proporção de 1/6, passando a totalizar em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Por fim, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, já que o réu é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais e não se vislumbra qualquer demonstração eficaz de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, motivo pelo qual ele faz jus à redução de 2/3, alcançando a pena o montante de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

O regime inicial de cumprimento será o ABERTO, uma vez que este se revela suficiente à prevenção e repressão do crime. Ressalto, aliás, a tendência de nossos Tribunais Superiores no sentido de que o tráfico em sua forma privilegiada (§ 4º do artigo 33) não é considerado como hediondo e, bem por isso, de que, se as demais circunstâncias do caso concreto não evidenciam a necessidade de fixação de regime rigoroso, é possível a fixação de regime mais brando.

Impossível, entretanto, a substituição da pena, uma vez que insuficiente a repressão do crime, especialmente diante das circunstâncias do crime (prática do tráfico nas imediações de estabelecimento de saúde), de forma a revelar que a aplicação de pena alternativa não seria socialmente recomendável.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO a ré KELVEN COSTA ROCHA à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 194 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração do artigo 33, "caput", cc. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a quantidade de pena estabelecida e o regime de cumprimento ora fixado, que, somados à primariedade e ausência de maus antecedentes, levam à conclusão de que não se fazem mais presentes os requisitos que justificam a manutenção de sua custódia cautelar.

Expeça-se o competente alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, §3º, do CPC, especialmente observando os rendimentos do réu, declarados em audiência.

Caso não haja recurso desta sentença, oficie-se para destruição das amostras do entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, cabendo ressaltar que por ocasião da audiência de custódia já houve determinação de destruição do entorpecente, reservando-se apenas o necessário à realização do laudo definitivo.

Com relação ao valor apreendido (R\$ 73,50 - fl. 18), tratando-se de produto do

tráfico, decreto seu perdimento em favor da União. Proceda-se conforme as determinações do artigo 63 da Lei de Drogas.

Quanto ao celular, não tendo sido requerida a restituição, decreto seu perdimento em favor da União, ressaltando que deverão ser apagados os dados pessoais que possam gerar constrangimento e/ou danos à honra e a imagem da pessoa. Preceda-se conforme as determinações do artigo 63 da Lei de Drogas. Contudo, caso não tenha condições de funcionamento, ou seja, tratando-se o celular de bem sem valor comercial, fica autorizada desde logo a destruição.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA